

1502050-31.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... forma, caracterizado o delito de tráfico em relação ao acusado Fernando, diante dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, da variedade e da quantidade de drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, além dos valores provenientes do comércio ilícito e das anotações da contabilidade do tráfico (fls. 204/205).

Até porque, nenhuma prova foi produzida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502050-31.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502050-31.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIA GERMANO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

MÁRCIA GENARO, ATILA KAUE LOPES DA SILVA e FERNANDO FELICIANO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios, vendiam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 36 (trinta e seis) porções de cocaína, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha e 204 (duzentas e quatro) porções de crack, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia total de R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) em dinheiro trocado, oriunda do comércio ilícito.

Recebida a denúncia (fls. 153/155), os acusados foram citados para oferecerem resposta à acusação, as quais foram apresentadas às fls. 180 (Márcia) e 189 (Fernando e Atila).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar dos acusados (fls. 191).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em memoriais, requereu a parcial procedência, requerendo

apenas a condenação do acusado Fernando, nos termos da denúncia (fls. 223/228). A defesa da acusada Márcia, por sua vez, pediu a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 233/237).

Por fim, a defesa dos acusados Átila e Fernando postulou a absolvição de ambos por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 238/242).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), pelo laudo de constatação (fls. 37/42), pelo laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 170/172), bem como pelos demais laudos periciais (fls. 204/211).

Por sua vez, a autoria foi comprovada somente em relação ao acusado Fernando, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, informou que "...é usuário de drogas há aproximadamente 20 anos; Que não tem residência fixa; Que não tem telefone para contato; Que tem dois filhos (5 e 10 anos de idade); que não estava traficando; Que estava apenas usando drogas no local." (fls. 18).

Em juízo, manteve a negativa e afirmou que não conhece os outros acusados. Contou que, no dia dos fatos, foi abordado quando estava dormindo num ponto de táxi, negando que estivesse em poder de uma mochila ou mesmo que tenha se dirigido até a barraca em que estavam Márcia e Átila. Disse que não conhecia os policiais que o prenderam, sem saber o motivo que teriam para inventar tais acusações.

Contudo, a versão do acusado Fernando foi totalmente desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A testemunha Claudinei, policial civil, em depoimento extrajudicial, relatou que "...foram investigar ocorrência de crime de tráfico de drogas, que estaria sendo realizado em uma Praça situada na Rua Marechal Deodoro nº.200, no Centro desta cidade. Os policiais realizaram campana no local, com viatura descaracterizada, por aproximadamente vinte minutos, onde observaram que um indivíduo posteriormente identificado como Fernando Feliciano, estava com uma mochila preta nas costas e, estava atendendo possíveis usuários de drogas. Em determinado momento, Fernando se dirigia a uma barraca montada no local, onde permanecia ali por alguns instantes e retornava. Os policiais procederam abordagem no indiciado Fernando, onde foi encontrado em sua posse a quantia de 17 invólucros de cocaína e 15 unidades de maconha. Também estava na posse de Fernando o valor de R\$69,00 em espécie (dinheiro trocado) e um aparelho celular, que foram apreendidos no presente registro. O policial civil condutor da ocorrência se dirigiu até o interior da barraca, onde estavam Átila e Márcia, sendo que junto a eles foram localizados uma pochete preta que continha R\$450,00 em espécie (dinheiro trocado), 19 invólucros de cocaína, 30 porções de maconha e 204 eppendorf de crack. Ante os fatos, os policiais civis conduziram os indiciados até este Distrito Policial, sendo que estes foram cientificados sobre seus direitos constitucionais e ouvidos através de Termo de Interrogatório. Diante do contexto fático, vislumbrando indícios suficientes de autoria e materialidade, a autoridade policial responsável exarou voz de prisão aos autores, em virtude das condutas se amoldarem ao artigo 33 da L. 11343/06." (fls. 23/24).

Em juízo, ratificou integralmente seu depoimento policial, acrescentando que, no dia dos fatos, foram abordados alguns possíveis usuários, os quais foram liberados em razão de nenhum ilícito ter sido encontrado em poder deles. Esclareceu que as porções de drogas localizadas na mochila e na pochete eram idênticas, sendo certo que referida pochete foi encontrada embaixo de um colchão e visualizou Fernando entrando um pouco na barraca, saindo em seguida. Por fim, afirmou que Márcia e Átila estavam deitados no mencionado colchão.

O policial civil Diogo, por sua vez, em depoimento judicial, corroborou o alegado por seu parceiro, confirmando a prisão em flagrante dos acusados e acrescentando que, no dia do ocorrido, Fernando ia até uma barraca, mexia em algo e voltava. Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos dos policiais civis, pois que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que visualizaram Fernando em plena traficância e localizaram parte das drogas e valores apreendidos em poder dele, tendo sido o restante das drogas e valores apreendidos localizados dentro de uma barraca onde estavam os corréus Atila e Márcia e para qual Fernando se dirigiu e mexeu em algo.

Assim, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Dessa forma, caracterizado o delito de tráfico em relação ao acusado Fernando, diante dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, da variedade e da quantidade de drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, além dos valores provenientes do comércio ilícito e das anotações da contabilidade do tráfico (fls. 204/205).

Até porque, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que as drogas apreendidas não seriam de propriedade dele ou que não se destinassem ao comércio ilícito.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

Com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Todavia, o acusado não preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, parágrafo 4º, da referida lei, não se aplicando a causa de diminuição de pena, em razão da comprovada reincidência de Fernando.

Por sua vez, deve-se reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão dos depoimentos dos policiais civis, é firme o suficiente para se concluir que o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.

No tocante aos acusados Atila e Márcia, por outro lado, não há provas suficientes para a condenação.

Na Delegacia de Polícia, a acusada Márcia aduziu que “...mora na rua; Que tem dois filhos (17/20 anos de idade); que é viciada em substância entorpecente (crack, cocaína, bebida alcoólica, álcool de posto de gasolina); Que encontra-se em alvará de soltura; Que não estava traficando e que estava apenas dormindo na barraca situada na praça (local dos fatos); Que quem estava traficando era seu companheiro Atila” (fls. 10).

Em interrogatório judicial, manteve a negativa, aduzindo que é usuária de drogas e, no dia dos fatos, fez um programa com Atila em troca de droga, acabou dormindo e sendo abordada no interior da barraca, na qual os policiais localizaram uma pochete com drogas. Disse que não sabia que havia droga no local e que referida pochete era dos acusados, que se conhecem há bastante tempo e vendiam drogas juntos. Revelou que, no dia do ocorrido, Fernando chamou Atila, que saiu da barraca, fechou o zíper e, assim, não conseguiu ouvir o que disseram, sendo certo que não viu aquele pegando droga no local.

O acusado Atila, por sua vez, em sede policial, afirmou que “...é usuário de crack há aproximadamente 17 anos; Que está desempregado; Que não tem endereço fixo; que

estava apenas dormindo na barraca na praça, sendo que estava fazendo programa com Márcia; Que passou a noite na rua bebendo e usando drogas e que perdeu o horário para retornar ao albergue; Que nega que estava traficando drogas no local.” (fls. 14).

Ao ser interrogado em juízo, também negou a prática do delito e aduziu que, no dia dos fatos, por ter ingerido bebida alcoólica e perdido o horário de entrada no abrigo social, acabou sendo convidado pela acusada Márcia, que não conhecia, em razão da chuva, para dormir no interior na barraca. Revelou que, assim, no dia seguinte, de manhã, foi surpreendido com a abordagem policial, sem que soubesse que havia droga no local. Negou ser usuário e ter conhecimento sobre a propriedade da pochete com as drogas e alegou também não conhecer Fernando e os policiais que efetuaram sua prisão, sem saber apontar qual motivo eles ou Márcia teriam para querer o prejudicar. Asseverou que não fez programa com Márcia e que disse o contrário na fase policial por ter sido induzido por alguém que não quis apontar. Pois bem. Como acima mencionado, nada indica que os policiais civis tenham imputado falsamente o crime de tráfico aos acusados Atila e Márcia. Contudo, as provas produzidas são insuficientes para condenação, em que pese as versões inverossímeis e mentirosas por ambos apresentadas em interrogatório judicial.

Isso porque, ainda que a pochete tenha sido encontrada na barraca onde os acusados Atila e Márcia estavam, não se comprovou se, realmente, pertencia a algum deles. É possível, apesar de improvável, que as drogas encontradas fossem somente do acusado Fernando, uma vez que, como bem disseram os policiais, foi visto entrando na barraca e mexendo em algo que estava em seu interior, sendo certo, ainda, que as drogas localizadas em poder dele, na mochila, e as encontradas na pochete, eram idênticas.

Pode até ser que os três estivessem traficando juntos, mas a prova, neste ponto, não é suficiente para condenação, até porque nenhum dos dois foi visto praticando atos de comércio ou surpreendido em poder da pochete.

O só fato de terem sido localizadas drogas na barraca em que estavam não pode levar a conclusão de que agiam em concurso com Fernando.

Repita-se que não se está aqui afirmando que Atila e Márcia não praticaram o delito, mas sim que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, que não pode ser presumida.

Assim, não havendo prova que demonstre terem praticado o delito de tráfico de drogas que aqui se apura e, não havendo provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser absolvidos.

Outro não é o entendimento de nossos Tribunais:

“A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se” (RT 714/357 e 358).

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ap. 162.055, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho).

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, impõe-se o desfecho de parcial procedência do pedido inicial. Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, “caput”, desta lei, considerando a personalidade desregrada do acusado, eis que o crime ora em julgamento foi praticado durante cumprimento de pena em meio aberto (processo de execução nº 0016679-25.2018.8.26.0041 – fls. 96), bem como à vista da significativa variedade e quantidade de drogas apreendidas, fixo-lhe a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (processo nº 0002250-45.2017.8.26.0540 – fls. 95) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, bem como a personalidade desregrada do acusado e a reincidência. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e que tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação da conduta, considerada grave.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar FERNANDO FELICIANO, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e absolver MÁRCIA GENARO e ATILA KAUE LOPES DA SILVA, qualificados nos autos, da imputação relativa ao crime previsto nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Declaro perdidos os valores apreendidos, que deverão ser destinados na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Estando o acusado Fernando preso provisoriamente, inaplicável o disposto no artigo 59 da Lei nº 11.343/06. Por tal razão, e, ainda, considerando a gravidade do delito, sua hediondez, a personalidade e a reincidência, bem como o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório. Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu no presente caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado Fernando na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se ainda necessário, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

No tocante aos acusados Átila e Marcia, à vista da absolvição, expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA